

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء  
+oOΛoUΣ+ I ΛoOoI UΣOΘ OΣI X EEoQIΘΣEEo  
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA



FSJES  
Ain Chock  
كلية العلوم القانونية والإقتصادية  
والإجتماعية عين الشق

**بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص حول:**

## النيابة الشرعية بين المذهب المالكي و مدونة الأسرة (المادة 231)

**تحت إشراف الدكتور:**

محمد بوشركة

**من اعداد الطالب:**

يوسف عيبي

**الرقم الوطني:**

R154004034

السنة الجامعية:

2020/2021

إهداء وشكر

إلى الوالدين..... فلولاهما لما وُجدتُ في هذه الحياة،  
ومنها تعلّمت الصمود، مهما كانت الصعوبات.

إهداء

إلى أساتذتي الكرام.....، فمنهم استقيتُ الحروف، وتعلّمت  
كيف أنطق الكلمات، وأصوغ العبارات.....

إهداء

إلى الزملاء والزميلات، الذين لم يدّخروا جهدًا في مدّي  
بالمعلومات والبيانات.

أهدي إليكم بحثي المتواضع

داعيًا المولى -سبحانه وتعالى- أن تُكَلَّلَ بالنجاح والقبول من  
جانب الدكتور المشرف

## مقدمة

إن عدم قدرة الطفل البدنية والفكرية على العناية بشخصه إدارة أمواله، تجعله يخضع  
للنيابة الشرعية التي يسندها القانون أو الأب أو القاضي على شخص آخر لا يتمتع بالأهلية  
القانونية، فهذه النيابة تهدف أصلاً إلى حماية القاصر من نفسه والحفاظ على أمواله على أن  
يصير قادراً على إدارتها وتسييرها..

فالأب يعتبر وليا على ابنه الشرعي بدون منازع ، ويمارس الولاية منذ ولادة الطفل إلى بلوغه سن الرشد القانوني (18 سنة شمسية كاملة) أو إلى أن تنتهي سواء كان ذلك بوفاة القاصر أو بوفاة الأب نفسه أو بتجريد هذا الأخير من ولايته بمقتضى حكم قضائي. فالولاية ملزمة للأب وبالتالي لا يمكن التملص منها. أما الأم، فلا يمكنها أن تمارس الولاية على أبنائها القاصرين مادام الأب على قيد الحياة.

والنيابة في اللغة مصدر ناب عنه نيابة إذ قام مقامه، أو اسم مصدر من نوب تنويبا، وهي نوع من الولاية، والولاية في اللغة هي النصرة المعنوية و القيام بالأمر أو عليه، وهي إما أن تكون أصلية، بأن يتولى الشخص عقدا أو تصرفا لنفسه إذا كان كامل أهلية الأداء بالغاً وعاقلاً وراشداً، أو نيابية بأن يتولى شخص أمور غيره.

والنيابة الشرعية ثابتة شرعا لفائدة العاجزين عن التصرف بأنفسهم بسبب الصغر والسفه وما في معناها، فقد أوردت آيات كثيرة تدل عليها؛ منه قوله تعالى: ﴿لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ وقولته سبحانه: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

ولقد سميت هذه النيابة التي مصدرها الشرع والقضاء لأن الشرع هو الذي يفرضها. وذلك بتحديد الوالي وتعيين مهمته، وتنظيم القواعد التي يسير عليها الوالي، مما يعني أن هذه القواعد امرة، لا حق لا للوالي ولا للمولي عليه في أن يقوم بتعديلها ولا بالاتفاق على ما يخالفها.

كما أن النيابة الشرعية عن القاصر في شؤونه الشخصية والمالية تكون إما ولاية أو وصاية أو تقديمًا ويقصد بالنائب الشرعي حسب المادة 231 من مدونة الأسرة والولي و هو الأب والأم والقاضي أو الوصي و هو وصي الأب أو وصي الأم أو المقدم الذي يعينه القضاء. فالولاية هي النيابة التي يمارسها الأب أو الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته عن أبناءه القاصرين. أما الوصاية هي النيابة التي يمارسها وصي الأب أو وصي الأم بموافقة قاضي القاصرين أثناء حياته للمحافظة على أموال أبنائه القاصرين والنظر في مصالحهم

وتدبير شؤونهم وذلك بعد مماته. بينما **التقديم** هو النيابة التي يمارسها الشخص الذي يعينه القاضي لإدارة وتسيير أحوال القاصر الذي لا أب له ولا أم تتوفر فيها شروط الولاية ولا وصي له ومما يشترط في المقدم أو الوصي أن يكون ذا أهلية كاملة حازما و أمينا.

### **فما هو مفهوم النيابة الشرعية شرعا و قانونا؟**

للإجابة على هذا التساؤل والتطرق لمفهوم النيابة الشرعية شرعا وقانونا يفترض علينا أن نخصص **(المطلب الأول)** للنيابة الشرعية في الشريعة الإسلامية (المذهب المالكي نموذجا) بينما نخصص **(المطلب الثاني)** لتعريف النيابة الشرعية في القانون (مدونة الأسرة)

### **المطلب الأول: مفهوم النيابة الشرعية في الفقه المالكي**

النيابة الشرعية حسب الفقه الإسلامي هي سلطة شرعية تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها، بحيث تترتب أثارها الشرعية عليها بمجرد صدورها، كما عرفت بأنها حقوق ممنوحة للأب أو لوصيه أو للحاكم محددة في التشريع الإسلامي على شخصية الولد وعلى أملاكه لمعاونته وحماسته حتى يصل إلى سن معينة يسر بنفسه

في الحياة، والنيابة مصدرها الشرع إذ ينظمها ويرتب درجات أشخاصها وأولويات كل شخص منهم بهذه النيابة، كما قد تكون مصدرها القضاء، حيث أن القاضي هو الذي يختار الشخص المناسب، ويضفي عليه صفة النيابة ليقوم بإجراء تصرفات قانونية في مصلحة شخص آخر يلزم القضاء أن يتهم به ويحمي حقوقه ومصالحه، وكذلك كتعيين مقدم على اليتيم الذي لا ولي له ولا وصي له وهو في أمس الحاجة إلى الرعاية والحماية. و النيابة الشرعية ثابتة شرعا لفائدة العاجزين عن التصرف بأنفسهم بسبب الصغر و السفه و ما في معناهما.

فقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل عليها منها قوله تعالى : ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا (6)﴾<sup>1</sup>

عبر الفقه الإسلامي عن نظام النيابة الشرعية تحت مسمى الولاية على الغير، ويقصد بالولاية على المال السلطة التي منحها الشرع لشخص على آخر، تجعل تصرفات الأول نافذة في حق أموال الثاني، وحقوقه المالية في الحال والمآل، صيانة لها أو لحقوق الأغيار عليها لقيام موجب اعتبره الشرع كذلك<sup>2</sup>. أو هي التي تجعل لصاحبها سلطة استثمار أموال المولى عليه وإجراء التصرفات القانونية الخاصة بها في الإطار الذي يسمح به القانون<sup>3</sup>.

1- القرآن الكريم، سورة النساء الآية 5 و 6.

2- عبد السلام الرفعي، الولاية في المال في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المذهب المالكي، مطابع افريقيا الشرق، طبعة 1996، ص 30.

3 - محمد الكشور، أحكام الحضانة، دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2004، ص 33.

ونقصد بالولاية على النفس، من منظور الفقه " الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة و حفظ و تأديب وتعليم وتزويج<sup>4</sup> "، وعبر عنها آخرون بكونها تلك " التي تثبت للولي في الأمور المتعلقة بشخص المولى عليه، من تربية و حضانة و تعليم وتزويج، وما إلى ذلك<sup>5</sup>"

وبهذا تختلف هذه النيابة عن النيابة العقدية التي تسمى الوكالة، لأن الموكل هو الذي ينشئها بإرادته ويتفق مع نائبه على مداها ومدتها وغير ذلك مما يلزم لتنظيمها. والنيابة مصدرها الشرع إذ ينظمها ويرتب درجات أشخاصها وألويات كل شخص منهم بهذه النيابة، كما قد تكون مصدرها القضاء، حيث أن القاضي هو الذي يختار الشخص المناسب، ويضفي عليه صفة النيابة ليقوم بإجراء تصرفات قانونية في مصلحة شخص آخر يلزم القضاء أن يتهم به ويحمي حقوقه ومصالحه، وكذلك كتعيين مقدم على اليتيم الذي لا ولي له ولا وصي له وهو في أمس الحاجة إلى الرعاية والحماية.<sup>6</sup>

أما الوصاية حسب المذهب المالكي فهي النيابة التي يمارسها وصي الأب أو وصي الأم بموافقة قاضي القاصرين أثناء حياته للمحافظة على أموال أبنائه القاصرين والنظر في مصالحهم وتدبير شؤونهم وذلك بعد مماته.

ومن خلال هذا يتبين لنا أن النيابة الشرعية تقوم على طرفين، الطرف الأول هم الأشخاص الخاضعون لنظام النيابة الشرعية، وهم تلك الطائفة من الأشخاص الذين يعانون من قصور في أهلية التصرف لديهم أو حل بهم مانع حال دون ممارستهم لأهليتهم ومباشرة التصرفات والعقود المختلفة، هؤلاء الأشخاص أخضعهم الشرع والقانون لنظام النيابة الشرعية

<sup>4</sup> - وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1989، دمشق، ص 3746.

<sup>5</sup> - عبد السلام الرفعي، الولاية في المال في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المذهب المالكي، مرجع سابق ص 21.

<sup>6</sup> - حددت أسباب الحجر في المذهب المالكي في سبعة: الصبا والجنون والرق والتبذير والفلس والمرض والنكاح في حق الزوجة. انظر الحطاب "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل"، المجلد الخامس.

لحمايتهم في أنفسهم وأموالهم في إطار المفهوم العام للضروريات الخمس الواجب المحافظة الأساسية في الشريعة الإسلامية. عليها طبقا للمبادئ

والطرف الثاني للنيابة الشرعية هم الأشخاص القائمين بمهمة النيابة الشرعية، وهم طائفة من الأشخاص كلفهم الشرع بمهمة الحفاظ على أنفس و أموال الخاضعين للنيابة الشرعية بصونهم و تنمية أموالهم، إما مباشرة عن طريق الأب أو الأم، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الوصي أو مقدم القاضي.<sup>7</sup>

قال الإمام مالك أن الوصي إن قبل الوصية ومات الموصي فقد لزمه القبول وليس له التراجع عنها بعد ذلك، وقال أشهب أن الوصي قادر على التراجع ما لم يمتهن الوصي لأنه في هذه الحالة لا يكون قد غر به لإمكانية استبداله، وإن لم يبذر منه شيء حتى مات الموصي له فله أن يقبل أو يرفض على أنه إن قبل الوصاية صراحة أو ضمنا بمباشرة أعمال الوصاية لزمته وإن لم يكن له أن يرجع عنها. أما إذا رفض الوصي سواء قبل موت الموصي أو بعده فليس له أن يعود ويقبلها.<sup>8</sup>

وقرر الدردير في الشرح الصغير أن للوصي أن يختار وصيا من قبله على من هو وصي عليهم وجاء في حاشية الصاوي تقييدا على ذلك أن الوصي يحتل واشترط في المقدم نفس الشروط المطلوبة في الوصي وتكون له نفس سلطاته، إلا أن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن المقدم تكون له سلطة على أموال القاصر دون شؤونه الشخصية فلا يتولى أمرا من أموره الشخصية،

7- أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص: العقود والمسؤولية، بعنوان 'النيابة الشرعية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ص 10

8 -- المادة 231

صاحب النيابة الشرعية:

- الأب الراشد؛
- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
- وصي الأب؛
- وصي الأم؛
- القاضي؛
- مقدم القاضي.

واعتبر آخرون أن المقدم لا يكون إلا في حالة الحجر على المجنون أو المعتوه أو السفه الذين تطرأ عليهم هذه العوارض بعد بلوغهم سن الرشد، و ذلك حين لا يكون لهم ولي شرعي أو وصي تعود له الولاية.

وختاماً فإن موضوع النيابة عن القاصر في التصرفات المالية؛ قد أحاطته الشريعة الإسلامية إلى جانب القانون المغربي بالعناية التامة، فقد تم وضع قيود وشروط على تصرفات الولي والوصي والمقدم في ممتلكات القاصر، وذلك لأجل الحد من تعسفهم في ممارسة أعمال الولاية والوصاية والتقديم، وهو الأمر الذي يستحق منا أيضاً البحث والدراسة والعناية العلمية، من أجل سد أي ثغرة قانونية من شأنها أن تستغل من طرف من جعلوا على تسيير ممتلكات هذه الفئة بما يمكن أن يعود بالضرر على ممتلكاتهم وحقوقهم.

### **المطلب الثاني: النيابة الشرعية في القانون (المادة 231 من مدونة الأسرة).**

إذا كان المحجور في جميع الأحوال محتاج إلى من يقوم بمصالحه ويرعى شؤونه الشخصية والمالية فقد اتفقت الشرائع السماوية والوضعية على طريقة وحيدة يمكن أن تتكفل بذلك، سميت في الاصطلاح باسم الولاية أو النيابة الشرعية.

وهذه النيابة الشرعية يقوم بها أشخاص ستة ورد النص عليهم في المادة 231 من المدونة على سبيل الحصر وهم: الأب الراشد والأم الراشدة، عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، والقاضي- ويسمى كل منهم وليا- وصي الأب ووصي الأم ثم مقدم القاضي.

كما أن أساسها حسب ما نصت لعيه مدونة الأسرة في المادة 230 أحد أمور ثلاثة: الأبوة والأمومة والقضاء.

وتبعاً لذلك، فالنائب الشرعي (الولي أو الوصي أو المقدم) إذا كانت له الولاية على المحجور حسب ما هو وارد في مدونة الأسرة، فإنه بالمقابل يتعين عليه القيام بصلاحياته المخولة له قانوناً، دون تقصير ولا إخلال، فما المقصود بهذه الصلاحيات؟ وما هي واجبات النائب الشرعي وجزاء الإخلال بها؟

## الفقرة الأولى: صلاحيات الولي في إدارة شؤون القاصر الشخصية و المالية

يقوم بمهمة الولاية على المحجور كل من الأب أو الأم أو القاضي،<sup>9</sup> إلا أن هذا الأخير رغم اعتباره وليا، فهو من حيث الواقع العملي ونظرا لكثرة مهامه وانشغالاته عادة ما يقوم بتعيين مقدما على القاصر يتولى رعاية شؤونه، لذلك فدراستنا لصلاحيات الولي ستكون مقتصرة على الأب والأم دون القاضي.

وإذا كان المقصود بالولي كل من الأب والأم<sup>9</sup>، فإن الولاية على المال تستند إليهما بالتراثبية، فالأب جعله المشرع في مقدمة الأولياء وهذا ما نصت عليه المادة 231 من مدونة الأسرة «صاحب النيابة الشرعية: - الأب الراشد....».

فهو الولي الطبيعي لابنه القاصر، وله الولاية القوية في المال التي تخول له في الأصل حق الاتجار بمال القاصر، وحق الإذن له التجارة ما دام ذلك في مصلحته.

وفي هذا الصدد، جاء قرار للمجلس الأعلى يؤكد ما سبق أن قلناه " القانون الذي يحكم النيابة الشرعية للمغاربة المسلمين هو مدونة الأحوال الشخصية التي تعطي للأب الولاية العامة لأولاده القاصرين، له الحق في التصرف في أموالهم بما في ذلك البيع دون إذن سابق من القاضي "<sup>10</sup>.

وتجدر الإشارة إلى أن الولاية التي يتمتع بها الأب هي مستمدة من الشرع مباشرة، وتسمى بالولاية الذاتية<sup>11</sup>، والذي يؤكد هذا الأمر المادة 236 من المدونة والتي تنص على أن " الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ما لم يجرّد من ولايته بحكم قضائي ".

<sup>9</sup>- هذا بالإضافة إلى القاضي الذي اعتبره المشرع وليا بصريح العبارة في المادة 231 من مدونة الأسرة.

<sup>10</sup> - قرار رقم 546 الصادر بتاريخ 14 ماي 1991، ملف شرعي 288.5433 منشور في مجلة المجلس الأعلى عدد 45 ص 108.

<sup>11</sup> - عبد الكريم شهبون، الشتفي في شرح مدونة الأسرة، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الاولى، 2006، ص 67.

ومن المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة في هذا المجال، هو اشتراط الرشد في الأب حتى يكون من أصحاب النيابة الشرعية<sup>12</sup>، وذلك يصرح الفقرة الأولى من المادة 231، وهذا الشرط لم يكن معمولاً به سواء في مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957، ولا في التعديل الذي عرفته في 10 شتنبر 1993.

والمقصود بالرشد حفظ المال وحسن النظر فيه والصالح، وكذا حسن إدارة وتسيير المال بصفة عامة<sup>13</sup>.

وفي ظل مدونة الأسرة تم فسخ المجال للأم لممارسة النيابة الشرعية على نطاق واسع حيث وسعت المدونة من مجال ولاية الأم على أبنائها، سواء على مستوى الحالات التي يحق لها أن تمارس فيها هذه الولاية أو على مستوى صلاحياتها، ففي غياب الأب إلى جانب حالتي الوفاة وفقد الأهلية المنصوص عليها في ظل تعديلات 1993 الطارئة على المدونة الملغاة، كما تم استعمال عبارة عامة في صياغة المادة 238 من مدونة الأسرة، والتي تنص على أنه "يشترط لولاية الأم على أولادها:

1- أن تكون راشدة.

2- عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان الأهلية أو بغير ذلك....".

أما ما يتعلق بالصلاحيات، فقد أصبحت للأم نفس صلاحيات الأب دون تمييز بينهما، حيث خول لها المشرع بمقتضى المادة 226 صلاحية الإذن لابنها القاصر بتسلم جزء من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار والتجربة دون أن يتوقف ذلك على إذن القاضي، بخلاف مدونة الأحوال الشخصية حيث لم يكن بإمكان الأم القيام بذلك، كما لم يكن بإمكانها تفويت جزء من أمواله إلا بعد الحصول على إذن القاضي، عكس الأب الذي كانت له الصلاحية في

12 - وهذا الشرط فرضته ضرورات الحياة وتعقيدها، فإذا كان الأب بالفطرة هو أأمن على أموال أولاده من أس شخص آخر، فإن هذا المعنى أصبح متجاوزاً أو غير مقبول، وذلك راجع إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وتفكك الروابط الأسرية، بحيث أضحت متوترة يغلب عليها الجانب المادي والمصلحة الشخصية، وهكذا أصبح من الممكن أن يستولي الأب على أموال أبنائه لظروف معينة أو تحت ضغط الحاجة والفاقة. 108.

13 - عمر لمين، مستجدات مدونة الأسرة فيما يتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية، الأيام الدراسية حول مدونة الأسرة، العدد 5 شتنبر 2004، ص 125.

ذلك، وهذا ما كانت تنص عليه المادة 148 من المدونة الملغاة " لا تفوت الأم أملاك القاصرين إلا بإذن القاضي".

وبالإضافة إلى هذت، فلأم صلاحية سحب الإذن الذي سبق أن أعطته لابنها القاصر<sup>14</sup>، وكذلك القيام في حالة حصول مانع للأب – كالمرض أو السجن مثلا- بالمصالح المستعجلة لأولادها (المادة 236 من مدونة الأسرة) والتي يتعذر انتظار حضور الأب لممارستها، مثل استخراج أو توقيع وثائق إدارية أو دفع نفقات عملية جراحية<sup>15</sup>.

كما يمكن للأم وبمقتضى المادة 238 من مدونة الأسرة، تعيين وصيا على ولدها القاصر، ولها أيضا حق الرجوع عن إيصائها متى استدعت الضرورة لذلك، هذا وقد أعطت المادة 239 للأم صلاحية أخرى تتمثل أساس في إمكانية اشتراط ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي تبرعت به لفائدة ابنها القاصر (المحجور) وفي حالة ما إذا توف هذا الشرط يصبح المتبرع النائب القانوني بخصوص المال المتبرع به.

أما في ما يتعلق بشؤون القاصر الشخصية، فالملاحظ أن المشرع المغربي قد اهتم بالولاية على المال بخلاف الولاية على النفس، حيث لا يوجد إلا بعض المقتضيات المتفرقة باستثناء ما يخص الحضانة ومنها ما جاء ضمن المادة 233 من مدونة الأسرة واليت تنص على ما يلي: " للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر... إلى بلوغه سن الرشد القانوني، وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي...".

وما جاء في المادة 235 من نفس المدونة: " يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكوين وإعداد للحياة...".

### الفقرة الثانية: صلاحيات الوصي و المقدم.

<sup>14</sup> - نصت على ذلك المادة 227 من مدونة الأسرة حيث جاء فيها " للولي أن يسحب الإذن الذي سبق ان أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك"

<sup>15</sup> - عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص 71.

## - صلاحيات الوصي:

وسعت مدونة الأسرة مهمة الوصي لتشمل حتى الولاية على النفس، وذلك من خال المادة 235<sup>16</sup>، حيث أعطى المشرع في المادة 251م أ صلاحية للوصي بأن يتقدم بملاحظة إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور لتغطية لوازمه، مع مراعاة ضيق أو سعة إمكانياته المالية، وحلو اختيار أحسن الطرق التي من شأنها تحقيق تكوين أحسن وتوجيه تربوي جيد وإدارة أموال القاصر على الوجه المطلوب<sup>17</sup>.

كما أن من صلاحيات الوصي بعد إقامة الإحصاء النهائي والكمال للأموال والحقوق المالية، ان ينجز ملحق به، يضاف إلى الإحصاء السابق، وينجز هذا الملحق بنفس الطريقة التي تم بها الإحصاء الأول.

## - صلاحيات المقدم:

إن تعيين المقدم يقتضي اتباع مسطرة خاصة منصوص عليها في المادة 244 من مدونة الأسرة، كما أن المقدم يجب أن تتوفر فيه شروط معينة حتى يكون أهلاً للقيام بصلاحياته. حيث جعل المشرع كل تصرفات المقدم مطلقة بل ترك الحرية له بالتصرف وقيد البعض منها بحيث تكون خاضعة لإذن القاضي لعدم وفور الشفقة الموجودة عند الأب أو الأم<sup>18</sup>.

ففيما يخص التصرفات غير المقيدة، فقد نصت عليها المادة 279، وتتمثل في بيع المنقولات التي تتجاوز قيمتها 5000 درهم والمعرضة للتلف، وبيع العقارات والمنقولات التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم، فمثل هذه التصرفات لا تحتاج إلى إذن القاضي<sup>19</sup>، وفي مقابل ذلك حددت المادة 271 التصرفات التي تستوجب إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين،

16 - تنص الفقرة الأولى من المادة 235 من مدونة الأسرة " يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.

17 - د. عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص 85.

18 - عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص 102.

19 - الدليل العلمي لمدونة الأسرة، جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، مطبعة البيت، سلا، العدد 1 أبريل 2007، ص 155.

فجميع التصرفات المذكورة في هذه المادة وما يجب على المقدم أن يستأذن القاضي عندما يريد التصرف فيها<sup>20</sup>.

### الفقرة الثالثة: واجبات النائب الشرعي وجزاء الإخلال بها.

#### - واجبات النائب الشرعي

##### أولاً: فتح ملف النيابة الشرعية.

لعل من أهم وأبرز الالتزامات التي رتبها المشرع على الولي، هي إلزام هذا الأخير بفتح ملف النيابة الشرعية، كلما تجاوزت قيمة أموال المحجور 200 ألف درهم حسب المادة 241 من مدونة الأسرة.

##### ثانياً: تقديم التقارير السنوية والنهائية.

عبرت المادة 243 من مدونة الأسرة عن هذه الالتزامات بما يلي: " وفي جميع الأحوال التي يفتتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقرير سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها."

وبالإضافة إلى هذه التقارير السنوية المنجزة من طرف الولي، فغن المشرع قد ألزم هذا الأخير بإنجاز تقارير نهائية مفصلة بعد انتهاء ولايته ببلوغ المحجور سن الرشد.

##### ثالثاً: إيداع النقود والقيم المنقولة بمؤسسة عمومية.

حفاظاً عن أموال القاصر منع المشرع، النائب الشرعي من مسك ما يعود للقاصر من أموال نقدية ووثائق ومجوهرات وكل المنقولات ذات القيمة، فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة 253 كمن المدونة انه: " يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية، والوثائق والحلي وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي."

#### - جزاء إخلال النائب الشرعي بمسؤولياته

20 - عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص 102.

تجدر الإشارة إلى أنه سواء تعلق الأمر بمساءلة الولي مدنيا أو جنائيا فإن قاضي شؤون القاصرين هو الطرف الذي يثير هذه المسؤولية وفق ما يظهر له من خلال صلته بالولي عبر التقارير التي يتسلمها، أو ما قد يبلغ به من طرف النيابة العامة وكل من تهمهم مصلحة القاصر، ويحيل الملف على النيابة العامة التي تحرك المتابعة المدنية أو الجنائية ضد الولي وترفعها إلى المحكمة، كما أن حماية أموال المحاجير تقتضي إضفاء طابع جزائي على كل من خولت له نفسه العبث بهذه الأموال، ولتحقيق هذه الغاية رتب المشرع المغربي مسؤولية مدنية للوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماتهما كما يمكن متابعتهم جنائيا عند الاقتضاء<sup>21</sup>.

نستنتج مما سبق مدونة الأسرة قد أحسنت صنعا بتقييد صلاحيات الوصي أو المقدم في التصرف في مال القاصر بالحصول على إذن مسبق من القاضي، فإن إطلاق يد الولي في التصرف في مال القاصر من شأنه أن يؤدي بمال القاصر لما ليست فيه مصلحة أمام عدم وجود أية رقابة قضائية قبلية عليه لذا وحسب فهمنا المتواضع يتعين تقييد تصرفات الولي في أموال ابنه القاصر، بإعادة النظر في المقتضيات المنظمة لأحكام الولاية.

---

21 - ينص الفصل 487 من القانون الجنائي " إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وليا أو خادما بالأجرة عندها... فإن العقوبة هي:

- السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484 ق.ج
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485 ق.ج
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485 ق.ج.
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486 ق.ج.

## لائحة المراجع

### أولاً: المراجع الفقهية

#### 1- الكتب

- عبد السلام الرفعي، الولاية في المال في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المذهب المالكي، مطابع افريقيا الشرق، طبعة 1996، ص 30.
- محمد الكشبور، أحكام الحضانة، دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2004
- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1989، دمشق

#### 2- الأطروحات

- أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص: العقود والمسؤولية، بعنوان ' النيابة الشرعية بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

### ثانياً: المراجع القانونية

#### 1- الكتب

- محمد الكشبور، أحكام الحضانة، دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2004
- عبد الكريم شهبون، الشتفي في شرح مدونة الأسرة، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الاولى، 2006
- عمر لمين، مستجدات مدونة الأسرة فيما يتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية، الأيام الدراسية حول مدونة الأسرة، العدد 5 شتنبر 2004
- الدليل العلمي لمدونة الأسرة، جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، مطبعة آليت، سلا، العدد 1 أبريل 2007

#### 2- الأطروحات

- أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص: العقود والمسؤولية، بعنوان ' النيابة الشرعية بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

## الفهرس

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2  | مقدمة.....                                                                  |
| 4  | المطلب الأول: مفهوم النيابة الشرعية في الفقه المالكي.....                   |
| 8  | المطلب الثاني: النيابة الشرعية في القانون (المادة 231 من مدونة الأسرة)..... |
| 9  | الفقرة الأولى: صلاحيات الولي في إدارة شؤون القاصر الشخصية و المالية ..      |
| 11 | الفقرة الثانية: صلاحيات الوصي و المقدم.....                                 |
| 13 | الفقرة الثالثة: واجبات النائب الشرعي و جزاء الإخلال بها.....                |
| 15 | لائحة المراجع.....                                                          |
| 16 | الفهرس.....                                                                 |